

为人从事合同约定相关经济活动，以及对犯罪数额较小的合同诈骗与诈骗竞合时如何适用法律存在一定争议，就本案定性，存在不同的意见：

第一种意见认为，被告人何某某不从事合同约定相关经济活动，应当定性为普通诈骗。判断是否构成合同诈骗要从行为人的主观故意、签订合同的本质以及有无履约可能等综合认定。本案被告人何某某在签订合同前即具有非法占有目的，自己不从事房地产销售及相关经济活动，通过中介面向不特定人员实施诈骗，签订合同的本质仅仅是诈骗的手段，假用合同的形式骗取他人财物，不具有经济合同活动特征，不构成合同诈骗罪。其以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物的行为，宜定性普通诈骗。

第二种意见认为，被告人何某某利用合同骗取对方当事人财物，应当定性为合同诈骗罪。被告人何某某冒用他人名义签订合同售卖“工抵房”，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，符合合同诈骗的犯罪特征。被告人何某某签订“工抵房”骗取他人财物的行为不仅侵犯了众多被害人正常购买房产的权益，而且对其他房地产销售公司正常销售房产造成影响，扰乱了市场经济秩序，其不从事房地产销售及相关行业不能阻却承担合同诈骗的责任。被告人何某某的行为虽然同时符合普通诈骗的犯罪构成，但应当优先适用特别条款合同诈骗罪定罪处罚。

笔者同意第二种意见，理由如下：

一、行为人是否从事合同约定相关经济活动不影响合同诈骗罪的认定

第一，从合同诈骗的设立及金融诈骗来看，均未对行为人从事职业作特别规定。原1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（已失效）第二条规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。1997年《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为定性为合同诈骗，至此将合同诈骗从普通诈骗中分离出来，列为特别条款独立成罪。合同诈骗罪位于扰乱市场秩序罪章节，判断构罪的关键是合同诈骗行为是否扰乱了市场经济秩序，而不是行为人从事职业扰乱了市场经济秩序。从金融诈骗相关罪名来

看，同属普通诈骗的特别规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款、进行金融票据诈骗活动、进行信用证诈骗活动、进行信用卡诈骗活动的，应分别定性为贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗行为。罪名区分的关键在于诈骗手段和侵犯客体，亦非行为人从事的职业。从合同诈骗条款的表述来看，诈骗的手段是利用合同，侵犯的是合同相对方的利益，判断是否成立合同诈骗的核心问题应围绕合同展开，对犯罪主体是单位还是个人或者行为人从事职业等并无特别要求。

第二，从社会危害性来看，与行为人是否从事合同约定相关经济活动无关。行为人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，既侵犯了被害人的权益，包括公私财物所有权，也侵犯了国家对合同的管理制度，同样侵犯了其他相对人可能与被害人签订合同的权益，扰乱了购方、售方、公共管理方共同组成的市场经济秩序，该合同诈骗行为带来的危害，与行为人是否从事合同约定相关活动无关，不会增加或减少上述社会危害性。以本案为例，被告人何某某通过中介宣传，骗取87名被害人签订了买卖合同或者协议缴纳“工抵房”定金，这对被害人作为购房者基于合同信赖通过正常途径购买房产造成影响，也对材料商等销售“工抵房”以及本市其他房地产销售公司销售房产均造成影响，导致消费者难以有序购买房产以及房地产销售公司丧失了潜在客户订单。客观上，案涉房地产销售公司在被告人何某某实施合同诈骗犯罪尚未被调查期间，听闻市场上有人销售“工抵房”而向市民发布公告，提醒不要相信低价“工抵房”，尤其是以供应商名义销售的“工抵房”，足以证明是被告人何某某实施的犯罪行为而非从事职业对本市房地产销售秩序产生重大影响。

第三，从定性争议来看，主观故意、签订合同的本质以及有无履约可能等是区分经济犯罪与经济纠纷的关键，而不是判断合同诈骗或是诈骗的标准。《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》规定，对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据表明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。合同诈骗犯罪与合同

